

1503305-44.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Carlos Alberto Corrêa de Almeida Oliveira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 25ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/03/2022

... do Estado de São Paulo: Apelação. Tráfico. Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Defesa pugna pela absolvição ante a insuficiência de provas. Pleiteia, subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal, o afastamento da agravante da calamidade pública, a aplicação do benefício do privilégio e a conversão em pena restritiva de direitos. Materialidade e autoria comprovadas. Pena ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

25ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1503305-44.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503305-44.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GEOVANE ALVES DE OLIVEIRA

Tramitação prioritária

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 09 de Março de 2022 nesta cidade e comarca de São Paulo, por força do Provimento 2545/2020, do Conselho Superior da Magistratura, após declaração de pandemia do COVID-19 pela Organização Mundial da Saúde, e Comunicado CG 284/2020, da E. Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo, a fim de garantir celeridade processual e ante a concordância das partes, instaurou-se audiência remota via aplicativo MICROSOFT TEAMS, sob a presidência do MM Juiz de Direito, Dr. CARLOS ALBERTO CORRÊA DE ALMEIDA OLIVEIRA, comigo Escrevente abaixo assinado, foi aberta a audiência de INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO, nos autos da ação supra referida. Presentes também à sala o Digníssimo Promotor de Justiça, Dr. Paulo Rogério Bastos Costa, a Defensora Pública, Dra. Fernanda Tartari Frazao de Vasconcelos e o acusado: GEOVANE ALVES DE OLIVEIRA, apresentado preso, escoltado e algemado, justificando-se o seu uso, nos termos da Súmula vinculante nº 11, do STF, para segurança dos presentes, uma vez que se trata de Sala de Audiências sem qualquer proteção, limitada apenas por janelas de vidro. Há enorme fluxo de pessoas, havendo fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia (funcionários, partes e público em geral), inclusive com arremesso de objetos, como já se teve notícia em dependência deste Complexo. Ademais, "O ministro Cezar Peluso reconheceu que o ato de prender um criminoso e de conduzir um preso é sempre perigoso. Por isso, segundo ele, 'a interpretação deve ser sempre em favor do agente do Estado ou da autoridade', como se colhe em <http://www.stf.gov.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=94467>. Iniciados os trabalhos, pelo MM Juiz foi dito que; Vistos. Diga à

defesa do acusado para apresentação da defesa preliminar. Pela defesa do acusado, foi dito que; MM Juiz, a defesa reserva-se no direito de manifestar-se sobre o caso ao final da instrução, sem prejuízo de requerer eventuais diligências, arrolando desde já as mesmas testemunhas da acusação. Em seguida, pelo MM Juiz, foi dito que; Vistos. Ratifico o recebimento da denúncia e não sendo o caso de absolvição sumária ou de rejeição, mantenho a mesma data da audiência para hoje em vista da economia processual e pelo fato do réu, vítima e testemunhas estarem presentes. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo. Ainda pelo MM Juiz, fazia consignar que iria iniciar as perguntas para facilitar o desenvolvimento da audiência, seguidas pelas partes, o que não causa qualquer prejuízo, bem como se deve a maior celeridade e objetividade na apuração, além do que não houve oposição pelas partes, não se podendo olvidar para os que entendem que se trata de nulidade, seria ela relativa e somente acolhida caso demonstrado efetivo prejuízo. Assim, foi ouvida a vítima; Ricardo Cesani de Oliveira e a testemunhas policial; Alexandre Paes Barbosa. Pelo Ministério Público, em concordância com a Defesa do acusado, foi dito que desistia da oitiva da testemunha policial; Wendel Gonsales Paulino, o que foi homologado pelo juízo. Em seguida foi realizado o interrogatório do réu, nos termos do novo art. 400, do CPP. As partes não tiveram requerimentos a fazer na fase do art. 402, do CPP, sendo assim, não havendo outras provas a serem produzidas, pelo MM Juiz foi declarado encerrada a instrução, estabelecendo-se a realização de debates orais, concedendo a palavra a cada qual das partes por vinte minutos. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, assim se manifestou: MM Juiz, o réu GEOVANE acha-se processados sob os fatos descritos na Denúncia. A Denúncia foi recebida. Resposta a acusação consta nos autos. Também nesta data houve a oitiva das testemunhas e interrogatório do réu. É o breve relatório. A Denúncia é procedente. E a prova produzida demonstra a autoria dos fatos pelo réu. Narra a vítima que foi informado da invasão de seu imóvel. A polícia apareceu rapidamente e abordou o réu que estava com coisas da vítima já separada para a subtração. Os policiais narram que receberam informe de pessoa que estava em um imóvel. Viram o réu no telhado que pulou do imóvel e dispensou uma caixa com os objetos da vítima. Para entrar no imóvel o réu pulou do telhado e escalou um portão de cerca de 3m de altura. O réu já havia separado objetos para a subtração. O réu admitiu aos policiais a prática dos fatos. O réu foi interrogado nesta data e confessou os fatos. Acrescente-se que a jurisprudência é pacífica em dar especial valor aos depoimentos da vítima e de seus representantes, bem como de policiais, já que normalmente, por desconhecerem o autor do delito, buscam com suas declarações, contribuir na apuração da verdade real, sem qualquer interesse escuso na punição gratuita e indevida de inocentes. A respeito do assunto encontramos os seguintes julgados: "Roubo - Vítima que segura e coerentemente, indigita e reconhece os agentes - Suficiência a embasar decreto condenatório. Mostra-se suficiente à condenação pela prática de roubo a palavra da vítima que, segura e coerentemente, indigita e reconhece os autores, com os quais se apreende parte das coisas subtraídas." (Apelação nº 550.571/9, Julgado em 02/02/1.989, 2ª Câmara, Relator: - Haroldo Luz, RJDTACRIM 2/135) - "Roubo-Clandestinidade - Palavra da vítima - Valor - Entendimento - Inteligência: art. 59 do Código Penal, art. 33, "c" do Código Penal- Em crimes tocados de clandestinidade, como é o roubo, sua palavra assume relevante significado probatório, sendo que o reconhecimento pessoal do agente do delito, quando feito com segurança e presteza e em harmonia com outras provas, é fonte segura de prova da autoria." (Apelação nº 803.157/5, Julgado em 17/06/1.993, 8ª Câmara, Relator: - S. C. Garcia, RJDTACRIM 18/126) - "Roubo - Palavra da vítima - Valor- Em delitos de roubo, cometidos em regra, na clandestinidade, a palavra da vítima é de suma importância quando coerente e segura em seus pontos essenciais, máxime se confortada por outros elementos de convicção." (Apelação nº 868.075/9, Julgado em 10/11/1.994, 7ª Câmara, Relator: - Nogueira Filho, RJDTACRIM 24/230) - "Testemunho de Policial - Valor- Inexiste impedimento para Policial figurar como testemunha, pois, depondo sob compromisso, suas informações devem ser cotejadas com as demais provas, não sendo possível passar-se um atestado de inidoneidade em

relação a uma pessoa, somente pelo fato de ser ela um Agente de Segurança, seja Civil, seja Militar." (Apelação nº 737.943/2, Julgado em 19/10/1.994, 5ª Câmara, Relator: - Walter Swensson, RJDTACRIM 25/334) - "Prova - Depoimento de Policial Militar - Credibilidade não afastada - Valor: STF - Ementa oficial: "Habeas corpus". Crime de roubo qualificado. Alegação de nulidade da decisão por falta de fundamentação, deficiência da Defesa e exagero na dosagem da pena. Sentença e acórdão devidamente fundamentados. Não há razão plausível para recusar a credibilidade das declarações de testemunha da acusação (policial-militar) que funcionou como segunda testemunha do flagrante, mormente quando resta confirmada a situação de flagrância após a instrução do processo-crime." "Habeas corpus" conhecido, mas indeferido. Habeas Corpus nº 72.540-6/SP - Segunda Turma - Relator: Maurício Corrêa - j. 15.4.96 - Paciente: Francisco de Assis Marques Arcanjo - Impetrante: Raimundo Olavo Gifone Rios - Coator: Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. (Habeas Corpus nº 72.540-6/SP, Julgado em 15/04/1.996, 2ª Turma, Relator: - Ministro Maurício Corrêa, RJTACRIM 30/532) - "Prova testemunhal - Depoimento de Policial - Valor: - Inteligência: art. 70, caput do Código Penal, art. 157, § 2º, I do Código Penal, art. 157, § 2º, II do Código Penal- A circunstância de ser Policial a testemunha não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra, pois, aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória, nem o inquina de suspeição, devendo-se aferir-se-lhe o mérito e medir-se-lhe o grau de confiabilidade, segundo os critérios ordinariamente aplicados." (Apelação nº 1.052.371/6, Julgado em 10/04/1.997, 7ª Câmara, Relator: - Souza Nery, RJTACRIM 35/303). Observa-se que o quadro probatório é robusto e seguro em apontar o réu GEOVANE como autor do furto tentado sofrido pela vítima, ante ao depoimento dos policiais que narram com clareza a conduta do réu e o surpreenderam quando estava com as coisas da vítima prontas para dela se apossar, sendo que o réu escalou o portão que guarnecia o imóvel, e o réu admitiu aos policiais a prática do furto. Some-se ainda que o réu confessou os fatos. Nesta esteira, observa-se que o furto não se consumiu, em razão da intervenção dos policiais que a impediram, pouco antes da posse pelo réu, e assim, restou a tentativa. Não é possível o reconhecimento da destruição de obstáculo, pois não restou indicada pelas testemunhas e nem há o laudo para materialização. Assim, pela PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA pelo furto tentado qualificado pela escalada. Quanto à dosimetria da pena, quanto ao disposto no artigo 59 do Código Penal, tem-se que GEOVANE na primeira fase consta que possui antecedentes. Na segunda fase consta a atenuante da confissão. Na terceira fase consta majorante de escalada e a minorante da tentativa. Dada a palavra à defesa do acusado, assim se manifestou: MM Juiz, GEOVANE ALVES DE OLIVEIRA, responde por infração, em tese, ao art. 155, § 4º, I e II, do Código Penal, por ter, supostamente, subtraído para si, mediante rompimento de obstáculo, bens pertencentes à vítima avaliados em R\$ 340,00. Em que pesem as ponderações lançadas pelo Ministério Público, a absolvição é medida de rigor, conforme se passa a demonstrar. 1. A atipicidade material da conduta (insignificância): Cumpre esclarecer que o ponto de destaque do Direito Penal em relação aos outros ramos jurídicos encontra-se na fragmentariedade, ou seja, o Direito Penal é o último sucedâneo utilizado para garantir a ordem jurídica e a paz social. Havendo qualquer ameaça de lesão ou lesão a um bem jurídico deve-se, imediatamente, procurar restabelecer a ordem jurídica por meio dos diversos ramos jurídicos. Somente quando nenhum deles conseguir cumprir este mister, o Direito Penal deve ser utilizado. Segundo a Teoria Constitucionalista do Delito, a tipicidade penal concretiza-se quando há tipicidade formal e material. A tipicidade formal configura-se quando há adequação de conduta a uma formulação típica legal. Já a tipicidade material configura-se quando houver resultado positivo relevante, imputação objetiva da conduta, imputação objetiva do resultado jurídico e, nos crimes dolosos, imputação subjetiva. A ausência de um dos elementos da tipicidade material ou a ausência de tipicidade formal exclui o crime. Conforme consta da denúncia, a res furtiva se resume a produtos que somados perfazem o total de R\$ 340,00 levando à conclusão lógica que o valor que supostamente foi objeto da tentativa de subtração não implica montante monetário significativo. Demais disso, não houve relevante

afetação ao bem jurídico, até porque a res foi recuperada. Diante de tal fato, torna-se possível e faz-se necessária a incidência do princípio da insignificância, bem como o consequente reconhecimento da atipicidade do fato. Ora, verifica-se que o dano patrimonial suportado foi juridicamente irrelevante, não subsistindo o delito. Deve-se consignar, aliás, que sequer houve qualquer detrimento patrimonial, visto que os bens foram imediatamente apreendidos e devolvidos à vítima. Logo, impõe-se a sua ABSOLVIÇÃO, nos termos do art. 386, inciso III, do CPP. Do crime de furto. Com efeito, da acurada análise do conjunto fático-probatório, produzido em Juízo, único capaz de sustentar um decreto penal condenatório (CF, art. 5, LIV e LV, c/c CPP, art. 155), verifica-se que a autoria delitiva não restou adequadamente prova pelos elementos coligidos na fase judicial. A vítima Ricardo Cesani de Oliveira, em juízo, disse que na manhã do dia 09 de fevereiro, foi informado pelo zelador do prédio ao lado a respeito de uma invasão no teto. É locatário do local e acionou prontamente a polícia. Não presenciou a prisão do acusado. O réu já estava capturado quando de sua chegada. O acusado pegou uma caixa completa que estava no terraço. Não houve arrombamento de porta, apenas transpôs o portão. O portão tem cerca de 1,90m, dois metros. Os objetos eram ferramentas de baixíssimo valor, que estavam separados para futura intimação. O policial militar Alexandre Paes Barbosa, em depoimento, afirmou que foram acionados pelo COPOM a respeito de um furto em andamento. Viu o réu no telhado ao chegarem, em posse de uma caixa com os pertences da vítima. Ele saiu pelo lado oposto das viaturas. O imóvel fica na esquina da Maracatins com a Açocê. A altura do telhado é de uns 7 metros. Há um portão de uma empresa vizinha, com cerca de 3 metros de altura. Os objetos estavam separados em uma caixa de hortifrutti. O acusado. As partes dispensaram a oitiva do policial militar Wendel Gonsales Paulino. Silente em solo policial, o réu, em juízo, disse que estava passando por dificuldades, pois é dependente químico. Já sofreu chacotas por parte de pessoas. Admite a prática delitiva. Ia furtar os objetos mesmo. Escalou um muro próximo à caixa de fios, de cerca de dois metros. Não houve arrombamento. Os objetos já estavam na caixa. A caixa estava na prateleira, deixou ela próxima ao ar-condicionado para pular de volta para a rua. Nunca foi internado por problema mental, só por dependência química. Sabe-se que a vítima pode ter seu depoimento interferido pelo nervosismo decorrente dos fatos, motivo pelo qual sua versão tem grande probabilidade de estar distorcida. Ciente de tais circunstâncias, o próprio legislador, desde logo, já afastou o acolhimento irrestrito do relato do(s) ofendido(s). Nesse sentido: "As declarações da vítima devem ser recebidas com cuidado, considerando que sua atenção expectante pode ser transformadora da realidade, viciando-se pelo desejo de reconhecer e ocasionando erros judiciais." (JUTACRIM, 71: 306). Conclui-se, então, pela falta de força probatória em relação à autoria. Nesse sentido, a i. Acusação, na tentativa de desincumbir-se do ônus da prova que grava suas alegações (CPP, art. 156), trouxe elementos insuficientes a comprovar sua versão. Como se sabe, o Direito Penal exige a convicção plena do julgador, ancorada em dados objetivos, concretos, irrefutáveis. A dúvida, menor que seja, milita em favor dos acusados, como determina o secular princípio do in dubio pro reo (CF, art. 5, LVII). A regra do in dubio pro reo também tem incidência quando se trata de estimar a interpretação que deverá prevalecer em matéria de norma penal incriminadora. Isso é assim porque o tipo penal tem função de garantia, consistente na indicação segura do comportamento proibido, de modo a preservar o indivíduo que não obra na linha que a lei penal interdita. A dúvida sobre a existência e autoria do crime é séria e, por isso, a única solução que se pode dar ao presente caso é aquela que prestigia o princípio in dubio pro reo. Neste sentido, não é possível ter a certeza jurídica necessária para atribuir a responsabilidade penal ao assistido pela infração penal. Diante deste contexto, data vênua, surge a dúvida que o favorece. O i. Ministério Público estadual não se desincumbiu do ônus da prova que é exclusivamente seu (CP, art. 156). Com efeito, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não foram produzidos quaisquer elementos que confirmem a imputação e isso prejudica sobremaneira a certeza que deve inspirar o julgador para reconhecer validamente a culpa do acusado. Sendo assim, diante da fragilidade probatória, pleiteia-se a ABSOLVIÇÃO, nos termos do art. 386, VII, do CPP. 3- Das Teses

Subsidiárias: Caso seja outro o entendimento desse d. Juízo, requer a Defesa Pública, de forma eventual: 3.1. Fixação da pena-base no mínimo: Ante a ausência de requisitos subjetivos capazes de elevá-la, deve a pena restar aplicada no mínimo legal. É dizer, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis, a teor do art. 59 do CP e da Súmula 444/STJ, destacando-se a primariedade técnica do réu. 3.2. O reconhecimento da tentativa e a aplicação da redução máxima em função do iter criminis percorrido: Com efeito, para o reconhecimento da consumação do crime de furto é necessário que o agente tenha disponibilidade da coisa, componente do bem jurídico imediatamente tutelado pela correspondente norma incriminadora – o patrimônio. Evidentemente, não é em todos os casos que essa inversão patrimonial se dá com a simples perda da vigilância do bem relatada pela vítima. Generalização dessa espécie implica confundir o mundo dos fatos com o mundo jurídico. E entre a realidade e a estrutura típica do delito há muito mais possibilidades do que se possa imaginar. Sob outro enfoque, no mundo dos fatos a consumação do delito não é apenas uma categoria jurídico-penal. Ela tem vida. E é representada pela efetiva inversão patrimonial, que se caracteriza pela posse tranquila da coisa, titularizada de tal modo pelo agente que ele possa dela dispor livremente. E não foi o que ocorreu no caso sob julgamento. Ao contrário, o acusado foi detido no contexto dos fatos, eis que houve uma denúncia anônima noticiando um furto em andamento. Assim, de rigor a incidência do art. 14, inciso II, do CP em fração proporcional ao iter criminis percorrido pelo acusado, ou seja, 2/3. 3.3. Afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo: Em primeiro lugar, porque se observa é que nenhum objeto fora subtraído do veículo, sendo que no caso a força física foi empregada contra o próprio bem que pretendia se subtrair, não podendo, dessa forma, ser considerado como rompimento de obstáculo. A respeito do assunto, vale lembrar o que dispõe Nelson Hungria: “Não é obstáculo, no sentido legal, a resistência inerente a própria coisa em si mesma, sendo indeclinável que a violência seja exercida contra um obstáculo exterior à coisa”. Ademais, de acordo com a denúncia, o furto em questão teria sido praticado mediante rompimento de obstáculo. Contudo, NÃO foi produzido laudo pericial para corroborar tal alegação. A necessidade de laudo pericial que demonstre a eventual forma anormal de acesso aos bens do veículo para a caracterização do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo é IMPRESCINDÍVEL também pela redação do art. 171 do Código de Processo Penal. Portanto, requer-se o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo. 3.4. Afastamento da qualificadora da escalada: Sabidamente, a qualificadora da escalada se configura quando agente, visando subtrair bens, utiliza via anormal para ingressar em imóvel. Esta via anormal deve demandar um esforço incomum, que demonstra um grande empenho do agente para a prática do delito. A escalada, por ser circunstância que deixa vestígios, deve ser comprovada por laudo pericial, em respeito ao disposto no art. 158, do Código de Processo Penal. Impende ressaltar que este dispositivo estabelece, expressamente, que nem mesmo a confissão do acusado não é suficiente para afastar a necessidade do exame pericial. A necessidade da prova pericial nestes casos é ainda reforçada pelo disposto no art. 171, do Código de Processo Penal, que prescreve: “Nos crimes cometidos com destruição ou rompimento de obstáculo a subtração da coisa, ou por meio de escalada, os peritos, além de descrever os vestígios, indicarão com que instrumentos, por que meios e em que época presumem ter sido o fato praticado” Na espécie, não foi realizada perícia no local dos fatos. Ante o exposto, na medida em que não houve emprego de esforço incomum, anormal, para a entrada no local, de rigor o afastamento da qualificadora de escalada. 3.5. Não procede o reconhecimento da agravante atinente ao estado de calamidade pública, pois nada indica que a pandemia facilitou de qualquer modo a prática do crime. Não consta dificuldade de patrulhamento por parte do estado, e em junho teve início a flexibilização das restrições até então impostas. No ponto, confira-se o entendimento esposado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: Apelação. Tráfico. Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Defesa pugna pela absolvição ante a insuficiência de provas. Pleiteia, subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal, o afastamento da agravante da calamidade pública, a aplicação do benefício do privilégio e a conversão em pena restritiva de direitos.

Materialidade e autoria comprovadas. Pena base devidamente exasperada. Agravante da calamidade pública afastada. Inviabilidade da aplicação do privilégio e da conversão. Recurso parcialmente provido. (grifei) (TJSP; Apelação Criminal 1510027-65.2020.8.26.0228; Relator (a): Reinaldo Cintra; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/11/2020; Data de Registro: 17/11/2020). FURTO QUALIFICADO - Conformismo defensivo quanto ao mérito da condenação e também em relação às qualificadoras reconhecidas - Pena-base bem exasperada em 1/3 diante do número de qualificadoras e também da insistência do réu em praticar crimes e do fato de ter sido praticado em um lar - Possibilidade de, no específico caso dos autos, afastar a agravante consistente na calamidade pública, por não parecer circunstância que facilitou o crime - Repouso noturno bem reconhecido, afastada a incompatibilidade com as qualificadoras - Possibilidade de alteração do regime prisional para o intermediário - Recurso parcialmente provido (voto nº 43394). (destaquei) (TJSP; Apelação Criminal 1510014-66.2020.8.26.0228; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 31ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/11/2020; Data de Registro: 16/11/2020) Furto qualificado - Pena base - Condenações antigas - Maus antecedentes - Configuração - Precedentes - Prejuízo causado pelo arrombamento - Invasão de estabelecimento comercial - Circunstâncias inerentes ao tipo, que não servem para justificar maior exasperação da pena base; Furto - Calamidade pública - pandemia de COVID-19 - Circunstância que não contribuiu para a realização do tipo - Agravante - Não configuração; Prisão em flagrante - Atenuante da confissão - Reconhecimento - Inteligência da Súmula nº 545, do c. STJ; Furto noturno - Estabelecimento comercial - Majorante - Incidência - Réu multirreincidente específico - Regime fechado - Cabimento - Detração - Matéria afeta ao juízo da Execução criminal - Recurso provido em parte para a redução da pena. (destaquei) (TJSP; Apelação Criminal 1507342-85.2020.8.26.0228; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 29ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/10/2020; Data de Registro: 13/10/2020) Caso este não seja o entendimento de Vossa Excelência, requer ao menos a compensação integral da referida atenuante com a agravante da confissão espontânea. 3.6. Detração e fixação do regime inicial menos gravoso (aberto ou, eventualmente, o semiaberto): para o início do cumprimento da sanção privativa de liberdade, considerando o quantum da reprimenda (CP, art. 33), e a ausência de circunstâncias pessoais e objetivas desfavoráveis (Súmulas 440/STJ; 718 e 719/STF). De rigor, ainda, a aplicação do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal. 3.7. A substituição de sanção corporal pela pena restritiva de direitos, a teor do artigo 44 do Código Penal. 3.8. Concessão do direito de apelar em liberdade (CADH, art. 8.1): De acordo com a lição de EUGENIO PACELLI OLIVEIRA, "[...] (probabilidade de fuga) e outra (a probabilidade de condenação) não são suficientes para, por si só, justificarem a prisão, dado que nenhuma delas atende a exigência constitucional, expressa na seguinte norma: ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente (art. 5, LXI)". No caso dos autos não há situação que demonstre a necessidade da prisão do réu, o que demonstra que a cognição cautelar referente ao periculum libertatis não encontra fundamento de validade no princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII) na concreta situação dos autos. Em seguida, pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte sentença: Vistos Etc. GEOVANE ALVES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, inciso II do Código Penal. Segundo a denúncia e o que consta nos autos do inquérito policial, em síntese, no dia 09 de fevereiro de 2022, em ocasião de calamidade pública, por volta das 08h19, no estabelecimento comercial situado na Avenida Açocê, nº 509, bairro de Indianápolis, nesta cidade de São Paulo, o acusado, mediante escalada de um portão, subtraiu, para ele 01 (uma) caixa granjeira avaliada em R\$ 50,00 (cinquenta reais), cabos elétricos avaliados em R\$ 200,00 (duzentos reais), 01 (um) serrote avaliado em R\$ 50,00 (cinquenta reais) e 01 (um) martelo avaliado em R\$ 40,00 (quarenta reais), pertencentes a Ricardo Cesani de Oliveira, cf. boletim de ocorrência de fls. 07/09, auto de

exibição, apreensão, entrega e avaliação de fl. 12 e fotografia de fl. 13. Porém, a ação delitiva foi percebida e o réu preso ainda dentro do imóvel. A prisão preventiva foi decretada. A denúncia foi recebida no dia 16 de fevereiro de 2022, oportunidade em que foi determinada a citação do réu para apresentar a defesa preliminar (fls. 77/79). A defesa preliminar foi apresentada. Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e uma testemunha, bem como foi interrogado o acusado. Encerrada a instrução, as partes apresentaram as suas alegações finais, oportunidade em que o Ministério Público pediu a condenação pelo crime de furto e a defesa pediu a absolvição pela insuficiência do conjunto probatório e pela insignificância da conduta, bem como o reconhecimento da tentativa. Apresentado o relatório, Decido. I. Não foi possível a suspensão condicional do processo porque o réu possui outro feito em curso, o que também impede o acordo de não persecução penal (fls. 105/108). II. A questão envolvendo o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão, bem como de eventuais vítimas das infrações penais não podem dar margem a uma premissa equivocada de parcialidade e de interesse em prejudicar quem quer que seja. Os policiais, bem como as vítimas pessoas físicas, como também os acusados, até prova em contrário, merecem o respeito por parte do Juízo. Inclusive, o conteúdo dos seus depoimentos e declarações, não são mais ou menos válidos e precisam ser analisados em conjunto com os demais elementos de convicção existentes nos autos. A defesa de postura diversa, respeitosamente, representa mero preconceito que precisa ser afastado em um processo judicial. Neste sentido, encontram-se os julgados do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, com destaque para o HC 165.561/AM, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, da 6ª Turma, publicado no DJe no dia 15/02/2016; HC 30.776/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, da 5ª Turma, publicado no DJe no dia 8/3/2004. Logo, a mera condição de policial ou de vítima não se prestam para afastar a credibilidade do conteúdo das informações trazidas para os autos, representando meio de prova eficaz e válido, ainda que isolado de outros elementos de convicção, desde que dentro de um contexto e de uma coerência, mormente quando avaliado diante das circunstâncias em que os fatos ocorreram e pela ausência de explicações e justificações adequadas por parte da defesa. III. A ação penal é parcialmente procedente. Ao final da instrução probatória, com base nos elementos de convicção existentes nos autos, a prisão em flagrante delito do acusado no local do crime, os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão, em todos os momentos em que eles foram ouvidos, sem me olvidar das declarações da vítima e da confissão do acusado, bem como do conteúdo das alegações finais, a procedência parcial da ação penal é de rigor. Conforme restou apurado, em síntese, no dia 09 de fevereiro de 2022, em ocasião de calamidade pública¹, por volta das 08h19, no estabelecimento comercial situado na Avenida Açocê, nº 509, bairro de Indianópolis, nesta cidade de São Paulo, o acusado, mediante escalada de um portão, subtraiu, para ele 01 (uma) caixa granjeira avaliada em R\$ 50,00 (cinquenta reais), cabos elétricos avaliados em R\$ 200,00 (duzentos reais), 01 (um) serrote avaliado em R\$ 50,00 (cinquenta reais) e 01 (um) martelo avaliado em R\$ 40,00 (quarenta reais), pertencentes a Ricardo Cesani de Oliveira, cf. boletim de ocorrência de fls. 07/09, auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação de fl. 12 e fotografia de fl. 13. Porém, a ação delitiva foi percebida e o réu preso ainda dentro do imóvel. Necessário consignar que o acusado foi preso ainda no imóvel, bem como sem que ele tivesse conseguido inverter a posse dos bens visados, os quais sequer saíram do imóvel em questão. O acusado ficou em silêncio na fase policial, mas acabou confessando o crime quando foi interrogado. Segundo o acusado, ele é usuário de drogas e estava passando pela necessidade do uso de entorpecentes, motivo pelo qual escalou o muro do imóvel em questão e retirou a caixa com os objetos para poder sair com eles. Porém, antes de conseguir a posse dos bens, os policiais chegaram e o prenderam. Tal confissão está em harmonia com o restante do conjunto probatório disponível, não existindo dúvidas de que o acusado escalou os tapumes do imóvel, os quais possuem mais de 1,90m de altura, restando provada a qualificadora em questão. Anota-se que a confissão do réu, corroborada pelas declarações da vítima e pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão dispensam a necessidade do laudo pericial do local do crime. Todavia, o crime em questão não se consumou, haja vista não ter invertido a posse dos bens, embora o

espaço percorrido tenha sido significativo., motivo pelo qual o redutor é de apenas 1/3. A desclassificação no caso para a figura tentada também foi requerida pela defesa e não há a necessidade de abertura de vistas para outras medidas, aplicando-se a inteligência do artigo 383 do Código de Processo Penal. Já com relação às alegações do princípio da insignificância e da atipicidade material, respeitosamente, entendemos que a conduta é descrita como crime, o réu é tecnicamente primário e os bens possuem valor econômico, tudo a indicar não ser cabível o reconhecimento do crime de bagatela ou a ausência de antijuridicidade. Anota-se que um bem imóvel foi invadido pelo réu, o qual tinha saído da cadeia há pouco tempo, demonstrando que o crime para ele é uma sequência de fatos e não algo episódico. Infelizmente, o réu, ao que tudo indica, é mais uma das dezenas de pessoas usuárias de drogas que praticam crimes de forma continuada para poderem sustentar o próprio vício. Importante mencionar que o Juízo não percebeu qualquer comprometimento da capacidade de valoração do certo e do errado por parte do acusado (culpabilidade). Também, por tudo que foi dito, não se verifica a possibilidade de nenhum benefício legal, em especial, o reconhecimento do privilégio no crime de furto. As teses defensivas restaram vencidas nos autos. IV. Demonstrada a procedência parcial da imputação contra o réu, não existindo justificativas para o seu ato, passo a dosimetria da pena a ser aplicada. Observando-se os elementos norteadores previstos nos artigos 59 e 60, ambos do Código Penal, a existência de uma qualificadora, bem como o fato de que o réu está em liberdade provisória por outro processo criminal, cuja condenação ocorreu em dezembro do ano passado (fls. 40/41), ou seja, demonstrando periculosidade real no risco social de novos ilícitos e adesão ao crime como meio de subsistência do próprio vício, as penas básicas são majoradas em 1/6, passando para 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias multa. Na segunda fase da aplicação da pena, considerando a confissão do acusado, as penas são reduzidas para o patamar mínimo legal de 02 anos de reclusão e 10 dias multa. A questão da agravante da calamidade pública impõe algumas considerações. Inicialmente, necessário um decreto que reconheça a situação de calamidade pública, sendo que no Estado de São Paulo isso ocorreu com o Decreto Estadual nº 64.879 de 20 de março de 2020, criado em face do advento da pandemia do COVID-19. Também, conforme entendimento majoritário da jurisprudência dos Egrégios Tribunais Pátrios se faz necessária a demonstração de que o estado de calamidade pública tenha de qualquer forma concorrido para o crime em questão. Portanto, o que se observa é que o critério não é apenas objetivo, devendo ser demonstrado que a situação de calamidade pública, de alguma forma, tenha permitido o crime praticado. Logo, verificamos que a nossa posição anterior de ser um critério objetivo não se sustenta no atual quadro jurisprudencial dos Egrégios Tribunais Pátrios, sendo as reformas das decisões em sentido contrário uma constante. Em face do exposto, atento ao posicionamento jurisprudencial, o qual é um modelador dos julgamentos dos magistrados de primeiro grau de jurisdição, revejo o meu posicionamento anterior para afastar a agravante da calamidade pública porque não restou demonstrado que tal situação tenha concorrido ou mesmo facilitado a prática do crime sob análise. No sentido do que foi acima exposto, destacam-se os julgados do Egrégio Superior Tribunal de Justiça junto ao HC 625.645/SP, Relator Ministro Felix Fischer, publicado no DJe 04/12/2020; bem como o julgado no HC 632.019/SP, Relator Ministro Felix Fischer, publicado no DJe 10/2/2021; o julgado no HC 629/981/SP, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, publicado no DJe 9/2/2021 e, finalmente, o que foi julgado junto ao HC 620.531/SP, Ministro Sebastião Reis Júnior, publicado no DJe 3/2/2021. Já na terceira fase da aplicação da pena, considerando a tentativa e o espaço significativo percorrido para a consumação do crime, as penas são reduzidas em apenas 1/3, passando definitivamente para 01 ano e 04 meses de reclusão e 06 dias multa, as quais torno definitivas. Fixam-se, cada dia multa no valor mínimo unitário legal, diante da falta de informações precisas sobre a situação econômica do réu. O réu é tecnicamente primário e possui periculosidade real, conforme já informado acima, razões pelas quais iniciará o cumprimento da pena no regime semiaberto, o único adequado no presente caso. Pelas mesmas razões, bem como pelo fato de que, em liberdade continuará a ameaçar a sociedade e poderá se furtar às consequências dos seus atos, fica decretada a sua

prisão preventiva com base no artigo 312 e ss. do Código de Processo Penal. Não é o caso de ser aplicado o artigo 387, parágrafo segundo do Código de Processo Penal, uma vez que o réu possui outros processos anteriores, o que determina uma análise do seu mérito subjetivo por parte do Juízo das Execuções Penais. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE, a ação penal para condenar GEOVANE ALVES DE OLIVEIRA, RG/SP nº 34454489, nascido em 07/08/1981, natural de Recife - PE, filho de José Carneiro de Oliveira e de Lúcia Alves de Oliveira, às penas de 1 ano e 04 meses de reclusão, com início no regime semiaberto, e 06 dias multa, no seu valor mínimo unitário legal, como incurso nas sanções do artigo 155, §4º, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, c.c. artigo 63, inciso III, alínea "d", todos do Código Penal. Nos termos da lei, condeno o acusado ao pagamento do valor equivalente a 100 UFESP a título de custas processuais, ficando suspensa a exigência em razão do acusado ser beneficiário da Justiça Gratuita. O acusado, pelas razões já apresentadas, não possui direito a nenhum benefício legal pela ausência de disciplina e por ser tecnicamente primário, representando qualquer benefício mero exercício de impunidade. Expeça-se ofício formalizador da prisão. Após o trânsito em julgado, o nome do réu deverá ser lançado no rol dos culpados. Deixo de fixar o valor mínimo da indenização, uma vez que não há prejuízos para a vítima em face da prisão do réu no local dos fatos. Apliquem-se aos bens apreendidos e não devolvidos o disposto no artigo 123 do Código de Processo Penal. Determino a perda dos objetos apreendidos em poder do acusado e como instrumentos do crime. Publicada a sentença após o término da audiência tendo as partes e o réu sido dispensados antes em razão do adiantado da hora e do próprio CDP ter outras audiências pelo MM Juiz, foi dito que: Vistos. Intimem-se as partes e o réu para tomarem conhecimento da sentença e se manifestarem com relação a eventual recurso no prazo legal. Nada mais. Nos termos do artigo 1.269 e seus parágrafos e 1.270 e seus parágrafos das Normas de Serviço dos Ofícios de Justiça expedidas pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, este termo é assinado eletronicamente pelo magistrado. Certifico e dou fé que as partes estão cientes sobre o respectivo teor; recebendo, Ministério Público e Defesa, caso assim solicitem, cada qual uma via assinada fisicamente pelos presentes. Registre-se e comunique-se. Autorizo Xerox. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, ____ (Wagner), escrevente, digitei e subscrevi.

MM Juiz: Assinatura Digital